

0001273-24.2020.8.26.0063

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME BECKER ATHERINO

Comarca: Barra Bonita

Foro: Foro de Barra Bonita

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... da pena. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, visto que foi reconhecida a associação para o tráfico entre Adilson e Kelly. Assim, afasto a incidência do redutor constante do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 por incompatibilidade com o reconhecimento do delito de associação para o tráfico. Desse modo, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barra Bonita

Foro de Barra Bonita

1ª Vara

Praça Dr. Meira, s/nº, Barra Bonita-SP - cep 17340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001273-24.2020.8.26.0063

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2050976/2020 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 10180182 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 1075/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 1079/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2050976 - DEL.POL.BARRA BONITA, 1075/20/406 - DEL.POL.BARRA BONITA, 1079/20/406 - DEL.POL.BARRA BONITA, 2050976 - DEL.POL.BARRA BONITA, 1075/20/406 - DEL.POL.BARRA BONITA, 1079/20/406 - DEL.POL.BARRA BONITA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELLY RODRIGUES DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME BECKER ATHERINO

Vistos.

KELLY RODRIGUES DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, em concurso material de delitos, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Concessão de liberdade provisória, mediante cumprimento das medidas cautelares em face da ré (fls.67/69).

Em razão da não localização da ré Kelly Rodrigues da Silva, não fora possível a realização de sua notificação. Sendo assim, houve desmembramento dos autos em relação ao processo do réu Adilson Silva (fl.373).

A ré foi notificada à fl. 441 e apresentou defesa prévia nas fls. 448/449.

A denúncia foi recebida em 24/08/2021 (fls.450/452).

Não havendo hipótese de absolvição sumária foi designada data para a realização da audiência de Instrução e Julgamento. Nesta audiência foram ouvidas duas testemunhas comuns e, ao final, interrogado a ré.

As partes apresentaram suas alegações finais, conforme mídia anexa.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Narra à denúncia que no dia 21 de fevereiro de 2020, na residência situada na Rua Aquiles Mengesso, n.110, Bairro Centro, na cidade de Igarapu do Tiete, comarca de Barra Bonita/SP, ADILSON SILVA DE JESUS e KELLY RODRIGUES DA SILVA, previamente ajustados entre si e agindo em concurso de agente guardavam e tinham em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, substancias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ademais, no mesmo dia, no Posto de Gasolina localizado na Avenida Pedro Ometto, n.1524, Bairro Jardim Vista Alegre, nesta cidade e comarca de Barra Bonita/SP, ambos os réus já citados, previamente ajustados entre si e agindo em concurso de agente, traziam consigo, para a entrega ao consumo de terceiros, 71 (setenta e um) eppendorfs de cocaína, pesando 57,4g; 01 (uma) porção de cocaína, com peso líquido de 10,8g, e 01 (uma) porção e 02 (dois) baseados de maconha, pesando 13,5g, além da quantia de R\$ 1.930,00 (mil novecentos e trinta reais) em dinheiro e 50 (cinquenta) eppendorfs vazios, drogas estas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, em data incerta, porém antes do dia 21 de fevereiro de 2020, na residência situada na Rua Aquiles Mengesso, n.110, Bairro Centro, na cidade de Igarapu do Tietê, comarca de Barra Bonita/SP, ADILSON SILVA DE JESUS e KELLY RODRIGUES DA SILVA, associaram-se para praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A materialidade dos crimes de tráficos e a dinâmica da associação restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl.02), boletim de ocorrência (fls.09/13), auto de exibição/apreensão (fls.14/15), laudo de constatação provisória de substância entorpecente (fls.18/20), fotografias objetos apreendidos (fls.34/38), relatório policial (fls.100/104), laudo pericial dos pinos vazios (fls.105/108), laudo pericial definitivo de entorpecentes que atestou positivo para as substancias apreendidas (fls.395/398), bem como toda a prova oral colhida.

Em fase inquisitiva a testemunha Thiago Teixeira de Almeida Prado, policial militar, disse que "já há várias semanas vinham chegando denúncias anônimas dando conta de que um casal, utilizando-se de um veículo GM/Classic, de cor branca, vinha realizando o tráfico de drogas no município, inclusive abastecendo as baladas aos finais de semana. Ocorre que nesta noite estava de serviço em companhia de seu colega de farda, quando avistaram, parado num posto de gasolina, o referido veículo, ocupado pelo dito casal, em razão do que decidiram efetuar a abordagem. O autor saía do veículo pela porta do condutor para pagar o abastecimento, quando foi surpreendido pelo depoente e seu colega. Em revista pessoal, encontraram com ele, nas mãos, a quantia de R\$ 1.930,00 em dinheiro, sendo que no bolso da calça localizaram 21 pinos de cocaína, prontos para a venda. Com a mulher, nada de ilícito foi encontrado. Ambos foram apartados, tendo a mulher admitido que eram companheiros e que faziam o tráfico juntos. Ela disse, ainda, que na residência do casal havia mais droga, para onde se dirigiram. Em referida casa, com a colaboração da autora, o depoente e seu colega encontraram, no quarto, dentro de um pote de achocolatado contendo arroz, mais 50 pinos de cocaína, igualmente prontos para a venda. Localizaram, ainda, uma pequena porção de cocaína, outra de maconha, dois baseados, além de 50 pinos vazios. A autora alegou que a maconha era somente para uso do casal. Com relação à cocaína, disse ela que usavam um pouco, mas que a maior parte destinava-se à venda. Em função de todo o ocorrido, foi dada voz de prisão aos autores, pela prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico, sendo ambos conduzidos a este plantão, onde também foram apresentadas as drogas e o

dinheiro”.

Em fase investigativa, a testemunha Tiago Fernandes Lucidio, policial militar, afirmou que “nesta noite realizava patrulhamento em companhia de seu colega de farda, na cidade de Barra Bonita, quando avistaram, num posto de gasolina, um veículo GM/Classic, de cor branca, ocupado por um casal, sobre o qual pesavam diversas denúncias anônimas de que ambos, utilizando-se do tal veículo, vinham realizando o tráfico de drogas no município, inclusive abastecendo as baladas aos finais de semana. Decidiram então efetuar a abordagem, sendo o autor surpreendido quando saía do veículo pela porta do condutor para pagar o abastecimento. Com ele, encontrou, nas mãos, a quantia de R\$ 1.930,00 em dinheiro, sendo que no bolso de sua calça localizaram 21 pinos de cocaína, prontos para a venda. Ambos foram separados, tendo a mulher admitido que eram companheiros e que faziam o tráfico juntos. Ela disse, ainda, que na residência do casal havia mais droga, para onde se dirigiram. Em referida casa, com a colaboração da autora, encontraram, no quarto, dentro de um pote de achocolatado contendo arroz, mais 50 pinos de cocaína, igualmente prontos para a venda. Localizaram, ainda, uma pequena porção de cocaína, outra de maconha, dois baseados e mais 50 pinos vazios. A autora alegou que a maconha era somente para uso do casal. Com relação à cocaína, disse ela que usavam um pouco, mas que a maior parte destinava-se à venda. Foi dada, então, voz de prisão aos autores, pela prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico, sendo ambos conduzidos a este plantão, onde também foram apresentadas as drogas e o dinheiro”.

Em juízo, a testemunha Thiago Teixeira de Almeida Prado, policial militar, relatou os exatos fatos já narrados por seu companheiro de farda, apenas esclarecendo que já possuíam denúncias a respeito de um casal que praticaria tráfico de drogas nas imediações dos quiosques da rua Sabino Bola, mais precisamente próximo a Toca do Caverna; que tinham o apelido do “Biro”, Adilson e a informação de que ele realizaria o tráfico em casal; que a informação era que eles mantinham a droga no interior do veículo e conforme as pessoas pediam a droga eles iriam buscar; que visualizaram o veículo sendo abastecendo e o abordaram; que do lado do passageiro, onde Kelly estavam, haviam cinquenta eppendorfs vazios idênticos aos vinte e um encontrados com Adilson; que Kelly de pronto foi colaborativa, confirmou a traficância e disse que tinha mais drogas em residência; que levaram isso a Adilson, que então também confirmou os fatos; que Kelly indicou na casa onde estaria o restante da cocaína, cinquenta eppendorfs cheios e uma porção a granel onde havia arroz cruz, sendo certo que dificilmente achariam sem que Kelly indicasse as drogas; que Kelly também informou que havia maconha no quarto, essa para consumo próprio; que não tinha informação de que Kelly era companheira de Adilson, mas a informação dava conta de que o casal fazia a venda; que possuíam inclusive o emplacamento do carro; que não se recorda se Kelly disse que vendia propriamente as drogas, mas a denúncia trazia a alcunha de Biro, mas que o casal sempre no veículo branco se passavam por frequentadores do local, sempre em conjunto, atuavam no tráfico de drogas.

Em juízo, a testemunha Tiago Fernandes Lucidio, policial militar, declarou a equipe tinha conhecimento por meio de várias denúncias de um casal praticando tráfico nos quiosques de Barra Bonita; que tinham inclusive a placa do veículo, um Corsa Sedan cor branca; que quando passavam pela avenida Pedro Ometto visualizaram o veículo abastecendo; que a denúncia dava conta de que os fatos ocorriam sexta e sábado; que havia uma terceira pessoa no banco de trás; que Adilson, vulgo Biro já desceu com uma grande quantidade de dinheiro na mão; que em um dos bolsos dele havia vinte e um pinos de cocaína; que com a ré nada de ilícito foi localizado; que com o outro indivíduo nada foi localizado; que ao lado do passageiro, do lado de Keilla, havia cinquenta eppendorfs; que Almir disse que estava de carona e o casal confirmou; que Biro manteve a versão de que a droga seria para uso próprio; que Kelly confirmou que eles realizavam o tráfico de drogas pelos quiosque e os eppendorfs vazios seriam para encher; que após indagar Kelly ela confirmou que havia mais drogas em casa; que foram ao local e encontraram cinquenta eppendorfs cheios de cocaína e uma porção bruta; que Kelly disse que a cocaína era para venda; que encontraram também maconha e cigarros de maconha no quarto, mas Kelly disse que essa droga era para

consumo próprio; que o local onde a droga estava escondida era difícil de visualizar e, por isso, se ela não tivesse indicado o local não conseguiriam achá-la; que as denúncias informavam o apelido de Biro, Adilson, sem citar o nome de Kelly, mas dando conta de que o casal realizava o tráfico; que na revista quando da abordagem não foi encontrada droga com Kelly, mas na porta, ao lado do passageiro, onde ela estava, foram encontrados os eppendorfs vazios; que todas as denúncias mencionavam que um casal estaria ali mais incisivamente de sexta e sábado; que apenas falava o apelido dele, a placa e as características do veículo; que foi Kelly quem indicou todas as drogas encontradas na casa; que ela inclusive indicou onde estava a cocaína e a maconha; que na primeira abordagem Adilson negou que a droga era para venda; que posteriormente Adilson admitiu que a droga era para venda; que Adilson na ocasião disse que a droga era vendida conjuntamente pelo casal; que o dinheiro Adilson disse que era fruto de seu trabalho; que os eppendorfs vazios estavam em uma sacola de supermercado da cor amarela no banco do passageiro onde Kelly estava sentada.

Em solo policial, a ré Kelly Rodrigues da Silva relatou que “tem a reclamar dos policiais militares alegando que eles fizeram pressão para que a interroganda entregasse uma arma de fogo que estaria escondida na casa. Porém, tem a dizer que nunca teve arma de fogo e nada sabe a respeito. Está ciente de que, por expressa proibição legal, não lhe foi arbitrada fiança criminal nesta fase policial, em razão do que permanecerá detida e será encaminhada para participar de audiência de custódia, pela manhã, após submeter-se a exame cautelar de IML”. Quanto aos fatos informou que “morava na cidade de São Manuel e mudou-se recentemente para Igarapé do Tietê, onde passou a morar com Adilson, seu atual companheiro. Em relação às drogas e à acusação de tráfico, não tem nenhum envolvimento com isso. Admite que Adilson ficou sem receber salário no trabalho e, por isso, ele começou a vender droga, mesmo com a desaprovação da interroganda. Assim, confirma os fatos ocorridos nesta noite, mas deseja deixar bem claro que toda a droga pertence a Adilson, que é quem vendia. A interroganda afirma que nunca vendeu e nunca participou das vendas de droga, não sabendo porque os PMS lhe acusaram”.

Em audiência a ré Kelly Rodrigues da Silva discorreu que tem 21 anos; que é casada; que tem um filho de sete meses; que não está trabalhando; que seu marido trabalha em uma empresa de ração e é dessa atividade que vem todo o rendimento da casa hoje; que estudou até o primeiro ano do ensino médio completo; que não é usuária de drogas; que nunca foi processada; que seu endereço é na Rua Venceslau, 70, Jardim Santa Mônica, São Manuel, São Paulo; que tem conhecimento das acusações que são imputadas.

Quanto aos fatos narrou que não tinha conhecimento da droga; que tinha conhecimento que estava no chão, mas não tinha conhecimento da droga que estava com ele; que foi muito pressionada pelos policiais que disseram que eles iam fazer com que ficasse presa e por isso acabou falando; que foram abordados no posto de gasolina; que estavam vindo de casa; que iam para uma pizzaria; que a pessoa que estava no carro era o primo de seu ex-marido; que os policiais bordaram e fizeram a vistoria e perguntas; que eles começaram a lhe pressionar; que a depoente perguntou para o Biro onde estava e ele explicou meio por cima e então a depoente levou os policiais até o local; que a depoente nunca teve envolvimento e não sabia o que era realmente; que pediu orientação para seu ex-marido para dizer onde as drogas estavam; que a quantia em dinheiro que estava com Adilson era oriunda de seu trabalho; que Adilson fazia bicos e tem casa de aluguel; que Adilson era usuário de drogas, maconha; que nunca vendeu drogas com Adilson; que nunca viu Adilson traficando; que estavam juntos há pouco tempo; que Adilson vendia drogas; que depois foi ter o conhecimento; que pouco tempo antes do ocorrido no posto tomou conhecimento, cerca de cinco dias antes; que tomou conhecimento pois via muita gente ligando para ele e a depoente acabou pressionando ele e ele acabou lhe falando; que a maconha encontrada na casa não era para venda; que nunca viu drogas na casa; que sabia que Adilson era usuário pois retornava para casa com cheiro; que a versão que Adilson disse em seu depoimento em Juízo não é verdade; que não é usuária de maconha; que não viu ele escondendo as drogas em casa, mas no dia dos fatos ele deu orientação para que a depoente informasse onde as drogas estavam; que

no posto perguntou onde as drogas estavam, assim que foram abordados. Quanto a pratica dos crimes de tráfico e associação para tráfico de entorpecentes, deve-se dar relevância aos depoimentos das testemunhas policiais. São eles os primeiros a presenciar os fatos e, de igual modo, ter contato com os envolvidos. No presente caso, os policiais já detinham diversas informações específicas relacionadas com o casal, veículo e nome do indivíduo masculino que fazia parte deste. Todas davam conta de que o casal se utilizava do veículo para realizar o tráfico de drogas na área dos quiosques de Barra Bonita.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os policiais faltassem com a verdade e incriminassem injustamente a ré. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado:

“Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 668/275), inclusive porque “o depoimento policial, como elemento de informação judicial, para ser acolhido, deve estar sempre acompanhado e confrontado por outras provas obtidas no curso da instrução processual, formando um todo coerente e logicamente harmônico, designativo da responsabilidade criminal do réu”(TJ/SP - Ap. Criminal nº 102.370-3 - rel. Márcio Bártoli, j. 03.04.91).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes. Não houve, ainda, contradição contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carregados aos autos, não contém qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Por outro lado, a parte ré apresentou depoimento contraditório com o que já havia prestado em sede administrativo e, ainda, com aquilo que foi dito por Adilson em Juízo, quando da audiência realizada no processo desmembrado.

A ré informou que nunca havia visto drogas na casa, que nunca vendeu drogas com Adilson, que não sabia que as drogas estavam com Adilson e que não sabia ao certo o que eram os cinquenta eppendorfs vazios, que estavam no assoalho do banco do passageiro onde a ré se sentava. Alegou, ainda, que logo que foram abordados perguntou para Adilson onde estariam as drogas escondidas em sua casa e, somente em razão de suposta pressão dos policiais, informou onde os entorpecentes estavam escondidos na residência.

Ora a prisão em flagrante da acusada, juntamente com seu ex-companheiro, decorreu de denúncias específicas que davam conta de um casal, cujo masculino era “Biro”, Adilson, que realizava a venda de entorpecentes por meio do veículo Corsa branco, sendo repassado inclusive o seu emplacamento. Além disso, apesar de Adilson ter tentado excluir a ré da conduta delituosa, ele mesmo informou que venderia entorpecentes na ocasião em que foram abordados acaso alguém lhe enviasse alguma mensagem. Assim, impossível dizer que a acusada não realizava o tráfico juntamente com seu ex-companheiro, quanto mais que não sabia da existência de drogas com ele, sobretudo levando-se em consideração os cinquenta pinos de cocaína encontrados no assoalho do banco onde estava sentado.

Desta feita, extrai-se do conjunto probatório elementos suficientes de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, considerando os depoimentos das testemunhas, bem como pelo fato de ter sido apreendido, na residência da acusada e de seu companheiro e com eles 71 (setenta e um) eppendorfs de cocaína, pesando 57,4g; 01 (uma) porção de cocaína, com peso líquido de 10,8g, e 01 (uma) porção e 02 (dois) baseados de maconha, pesando 13,5g, além da quantia de R\$ 1.930,00 (mil novecentos e trinta reais) em dinheiro e 50 (cinquenta) eppendorfs vazios.

Os policiais foram categóricos em narrar os fatos, bem como explicar a forma em que as drogas estavam acondicionadas, e o procedimento que os acusados utilizavam para a venda. A acusada e seu ex-companheiro escondiam as drogas no interior do veículo e quando recebiam alguma mensagem ou chamada, encontravam-se com o comprador e, então, vendiam os entorpecentes.

Ressalta-se ainda ser irrelevante não ter a acusada sido encontrada em atitude direta de venda ou inexistir qualquer anotação com a contabilidade do tráfico ou dinheiro apreendido nos autos, pois basta a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, para a configuração do crime, em que o dolo é genérico.

Portanto, não é indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolvem a acusada.

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

"Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido". (RT 729/542). Assim, considerando a prova dos autos, a localização dos entorpecentes, a quantidade apreendida, a forma que estavam acondicionadas e os objetos comumente utilizados para a preparação das drogas para a venda, assim como os depoimentos das testemunhas, comprovado está que os entorpecentes encontrados na residência, eram destinados ao consumo de terceiros.

No tocante ao delito previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, este resta caracterizado quando duas ou mais pessoas se associarem (reunirem-se, juntarem-se) com a finalidade de praticarem (realizarem, cometerem) os crimes previstos nos artigos 33, caput, da lei 11.343/06. O artigo 35 descreve como tipo do crime a associação para o fim de praticar o tráfico, reiteradamente ou não.

Os próprios acusados apresentaram versões contraditórias, com evidente intuito de se evadirem da aplicação da lei penal, mas que demonstram que se conheciam previamente. Eram um casal e, como já dito, a denúncia recebida pelos policiais mencionava a traficância realizada por um casal num veículo Corsa Classi, de cor branca. Ainda, Kelly residia com Adilson no mesmo imóvel e indicou a localização de todos os entorpecentes escondidos. Por fim, os policiais militares, que nada tinham contra a acusada Kelly, informaram que ela mencionou que a droga era destinada à venda, mas que a maconha encontrada na residência era para seu consumo pessoal. Por sua vez, Adilson, quando de sua oitiva judicial, informou que a maconha era de Kelly, pois ela seria usuária.

Ainda nessa linha, além depoimentos contraditórios dos acusados, como já informado anteriormente, resultou claro que seria impossível a acusada não saber da existência de drogas no interior do veículo e no interior de sua casa. Foi ela quem indicou onde os entorpecentes estavam escondidos, num pote de achocolatado repleto de arroz e, ainda, estava sentada no banco onde foram encontrados outros cinquenta pinos vazios de cocaína. Não é verossímil que tenha perguntado essa informação a Adilson assim que a abordagem se iniciou.

Resultou, assim, caracterizada a estabilidade da associação haja vista que, além de comprovado o crime de tráfico, como já demonstrado, a acusada e seu ex-companheiro eram um casal e ambos participavam das vendas usando o carro, veículo Corsa, branco. Tanto é verdade que no momento da abordagem policial, ambos estavam no carro com a importância em dinheiro e a droga apreendida. Portanto, não há que se falar em crime isolado por parte de somente um réu. Mais ainda, no momento da abordagem do veículo descrito na denúncia, embaixo do banco do carona, onde Kelly estava, fora encontrada grande quantidade de embalagens para armazenamento de drogas, o que faz crer que ambos, de fato, se associaram para o comércio ilícito de entorpecentes.

Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Criminal nº 0013027-77.2014.8.26.0481:

(...) Patente, ainda, o "acerto" ou divisão de funções delineando o animus associativo ou a união formada para o sucesso do tráfico, com a convergência de vontades e divisão de tarefas entre os réus, segundo se verifica do cotidiano de

traficantes “bem estruturados” que exercem a espúria atividade, daí, também, a infração penal prevista no artigo 35 da Lei nº. 11.343/06, tal como sustentou o Ministério Público via apelo. Vale registrar que “O art. 35 da atual lei reproduz integralmente a conduta que era prevista no art. 14 da lei antiga, que continuou sendo chamada de associação ao tráfico, exigindo inclusive que a conduta tenha o fim de reiteradamente ou não praticar os crimes definidos no art. 33, caput e § 1º, tendo apenas alterado a pena de multa, que foi aumentada, acrescentando o parágrafo único” (VICENTE GRECO FILHO e JOÃO DANIEL ROSSI, “Lei de Drogas Anotada”, 1ª ed., Saraiva, 2007, art. 35, pág. 119, grifei). “Pouco importa, dessa forma, se os agentes desejam ou não a prática reiterada do crime de tráfico, bastando a associação para a prática de um único crime” (ROBERTO MENDES DE FREITAS JÚNIOR, Drogas, 1ª ed., J. Oliveira, 2006, item 6., pág. 74). Destarte, os acusados, como ficou claro, estavam “ligados” entre si por um animus associativo (ou ajuste prévio), objetivando a prática, reiterada ou não, do crime de tráfico, daí as duas infrações penais descritas na denúncia, sem se ignorar que a associação eventual também não afastaria o delito descrito no artigo 35 da Lei nº. 11.343/06. Para melhor realçar a associação, importa destacar que somente pessoa enfronhada no “mundo do crime” pode obter tamanho volume de drogas capaz de abastecer vários usuários, servindo o detalhe para indicar integração a organização criminoso. Faz-se tal apontamento apenas a título de argumentação, porquanto as anotações, aliadas à grande quantidade de tóxicos e embalagens vazias apreendidas, denotam até mesmo a reiteração criminoso.

Portanto, suficientemente provados os fatos narrados na denúncia, configurando-se os crimes ali descritos.

Assim, porque comprovada a prática do fato típico, e não verificada a existência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação da requerida por infrações ao disposto no artigo 33, caput e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, em concurso material de delitos, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Passo, agora, à dosimetria da pena.

-Delito previsto no artigo 35, caput, da Lei 11,343/06.

Atento ao que estabelece o artigo 59 do Código penal, não se verifica a presença de elementos que importem um maior juízo de reprovabilidade da conduta além daquele inerente ao próprio tipo penal. Fixo, assim, a pena base em 03(três) anos de reclusão, e pagamento de 700(setecentos) dias-multa.

Não concorrem circunstâncias agravantes na segunda fase da dosimetria. Restando apenas a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, por se tratar de ré menor de 21 anos na data do fato. No entanto, nessa fase do processo dosimétrico, é necessário respeitar as margens de mínimo e máximo legal estabelecidas, não sendo possível diminuir a pena aquém do mínimo legal. Mantenho, assim, a pena intermediária igual à do patamar acima, no mínimo legal.

Na última fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena. Fixo a pena em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

-Delito previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais a serem consideradas, nos termos do artigo 59 do Código penal e 42, da Lei 11.343/06, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não concorrem circunstâncias agravantes na segunda fase da dosimetria. Restando apenas a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, por se tratar de ré menor de 21 anos na data do fato. No entanto, nessa fase do processo dosimétrico, é necessário respeitar as margens de mínimo e máximo legal estabelecidas, não sendo possível diminuir a pena aquém do mínimo legal. Mantenho, assim, a pena intermediária igual à do patamar acima, no mínimo legal.

Na última fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, visto que foi reconhecida a associação para o tráfico entre Adilson e Kelly. Assim, afasto a incidência do redutor constante do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 por incompatibilidade com o reconhecimento do delito de associação para o tráfico. Desse modo, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Sobre a incompatibilidade da concessão do benefício do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n.11.343/06 quando presente a associação do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, o STJ já decidiu: "Conforme mansa orientação jurisprudencial desta Corte, a condenação pelo crime de associação para o tráfico configura circunstância que, por si só, constitui óbice à concessão da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas" (AgInt no HC 467.201/SP, j. 12/03/2019).

Entre os delitos deve ser aplicada a regra do concurso material de crimes, que impõe a cumulação das penas (artigo 69 do Código Penal). Foram dois crimes praticados mediante duas condutas distintas. Isto posto, fixo a reprimenda final em 08 (oito) anos de reclusão, e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa. Inexistindo elementos suficientes para reconhecer a capacidade financeira da ré, fixo o dia-multa em 1/30 do salário mínimo nacional.

Na forma do artigo 33, § 2º, alínea "a", e § 3º, a pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicialmente semiaberto, em razão do quantum de pena aplicado, a primariedade da acusada e ausência de antecedentes.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito não é cabível na espécie, uma vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal (artigo 44, inciso III, do Código Penal). Ademais, diante do quantum da pena aplicada, entendo ausentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal. Ausentes, de igual modo, os requisitos do artigo 77, do Código Penal. Deixo, assim, de conceder o sursis a apenada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a ré KELLY RODRIGUES DA SILVA, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional, por infração ao disposto no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06.

Como assim respondeu ao presente feito, concedo a ré o direito de recorrer em liberdade.

Custas pela condenada, na forma do artigo 4º, § 9º, da Lei nº 11.608/03, ressalvada a gratuidade da Justiça.

Fixo os honorários advocatícios em 70% da tabela, expedindo-se o necessário desde logo e ficando o restante a ser apreciado quando do trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, (i) intime-se a ré para o pagamento da pena de multa; (ii) expeça-se a guia de execução definitiva; (iii) expeça-se ofício ao IIRGD e ao TRE.

P.I.C.

Barra Bonita, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA